

1517533-73.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... denúncia de local em que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes, nas proximidades da Escola Estadual Jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda, a qual dava conta que três indivíduos que se encontravam próximo a escola fazendo tráfico de substâncias entorpecentes. Juntamente com seus colegas Leandro e Edson rumaram para o local denunciado e lá chegando lograram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517533-73.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517533-73.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

desconhecido e outros

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

IAGO TAVARES MARTINS, EVERSON RODRIGO MARQUES DE SOUZA DOS SANTOS e VINÍCIUS AGOSTINHO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 9 de maio de 2022, na Rua São Candido, nº 767, Pirituba, nesta cidade e Comarca, teriam se associado para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes e teriam trazido consigo para entrega a consumo de terceiros 11 porções de maconha, 212 porções de cocaína e 57 de Skunk, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, os acusados teriam se associado, com nítida divisão de tarefas, para a venda de entorpecentes no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Em suma, o acusado EVERSON teria como função auxiliar na prática do tráfico e exercer a função de "olheiro", uma vez que se posicionava à frente de um bar na mesma rua, no numeral 792, sendo incumbido de avisar aos demais sobre a eventual chegada da polícia, bem como indicava também a usuários o local exato onde estava sendo realizado o comércio de entorpecentes. IAGO e VINÍCIUS, por sua vez,

teriam como função exercer a prática da narcotraficância.

Consta, também, que policiais civis receberam uma denúncia que indicava a prática de tráfico de entorpecentes no local, que fica nas proximidades da Escola Estadual Jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda, por três indivíduos. Imediatamente, os policiais rumaram para o local indicado, onde flagraram três indivíduos com as características denunciadas, posteriormente identificados como sendo os ora acusados IAGO, EVERSON e VINÍCIUS.

Após efetuarem a abordagem dos acusados, os policiais apreenderam na posse de IAGO e VINÍCIUS as substâncias entorpecentes retro mencionadas, já embaladas e prontas para a distribuição.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 74).

A denúncia foi oferecida às fls. 104/108.

A decisão de fls. 152/153 determinou a citação e notificação dos acusados, reservando desde logo data para realização de audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 09 de agosto de 2022.

Citação e notificação de Iago a fls. 190 e de Everson a fls. 191 e defesa prévia de ambos, pela DPE, a fls. 196/197.

Citação de Vinicius a fls. 192 e defesa prévia a fls. 109/110, apresentada por meio de advogado constituído (procuração a fls. 111/112).

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 198).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas Rogério Grolla, Edson Bury Roso e Leandro Luiz Martins, tendo sido os réus interrogados ao final. Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a fls. 213/221 a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia vez que comprovados indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Quanto à dosimetria da pena, requereu sua fixação acima do mínimo legal, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas em poder dos réus, salientando também que EVERSON é reincidente. Por fim, pugnou pela não aplicação do redutor legal, vez que incompatível com o crime de associação para o tráfico e, fixação do regime prisional fechado.

Já, a Defesa (réu IAGO - fls. 234/241; réu EVERSON - fls. 225/226; réu VINÍCIUS - fls. 227/229) pugnou pela absolvição dos acusados por falta de elementos concludentes para a condenação deles, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu aplicação do redutor legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2.006, tendo em vista que se tratam de pequenos traficantes, salientando-se que houve confissão acerca dos fatos. Requereu também absolvição no tocante ao crime de associação vez que a prova produzida em Juízo não comprovou o efetivo conluio entre eles para a prática do crime de tráfico, afastamento da qualificadora prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2.006 vez que não há provas de que estavam naquele local para vender drogas a alunos da Escola Jornalista Carlos Frederico W. Lacerda, aplicação do redutor legal e, fixação de regime prisional diverso do fechado, além da possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Ausentes questões preliminares, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 14), laudo de constatação (fls. 10/13), laudo pericial definitivo (fls. 172/174), além da prova oral colhida em Juízo. No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia.

Vejamos.

O réu IAGO TAVARES MARTINS, na fase policial, exerceu o direito constitucional de permanecer calado (fls. 30).

Ouvido em Juízo, afirmou ser casado, ter uma filha, ter cursado até o 1º Ano do Ensino Médio, ser viciado em cigarro, trabalhar como barbeiro. Confessa os fatos,

disse que era uma das primeiras vezes que estava no tráfico de entorpecentes, em razão de dificuldades financeiras, quando já foi abordado e preso por policiais. Admite que existe uma escola em rua próxima ao local onde foi preso. Ressaltou que o réu Vinícius era "olheiro, mas não conhecia Everson antes dos fatos, salientando que não estavam juntos.

O réu EVERSON RODRIGO MARQUES DE SOUZADOS SANTOS, na fase policial, exerceu o direito constitucional de permanecer calado (fls. 31).

Ouvido em Juízo, disse ser solteiro, sem filhos, ter estudado até o 9º Ano do Ensino Fundamental, ser viciado em "maconha" e "cocaína" e, trabalhar como "motoboy". Negou qualquer envolvimento nos fatos. Disse que estava num bar localizado na esquina do local onde se deu a prisão dos demais réus, quando surgiram policiais no recinto perguntando quem já registrava passagens policiais anteriores. O réu, então, acabou admitindo, sendo levado por eles. Por fim, disse que nunca tinha visto aqueles policiais antes do dia de sua prisão e, que já foi preso anteriormente em razão de porte de armas e roubo.

O réu VINÍCIUS AGOSTINHO, na fase policial, exerceu o direito constitucional de permanecer calado (fls. 32).

Ouvido em Juízo, afirmou ser solteiro, sem filhos, ter estudado até o 1º Ano do Ensino Médio, ser viciado em drogas e álcool, bem como, trabalhava realizando "bicos". Confessa os fatos narrados na denúncia. Disse que estava no local como "olheiro" e, em local próximo à prisão deles existe uma escola.

A confissão prestada em Juízo pelos acusados Vinícius e Iago, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra a realidade da hipótese acusatória.

Mas, apesar das negativas do réu Everson acerca de seu envolvimento nos fatos imputados a ele na denúncia, a procedência da denúncia também é medida que se impõe.

A testemunha policial civil Rogerio Grolla, em fase policial (fls. 16/17), relatou que, "o colega do depoente Leandro recebeu denúncia de local em que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes, nas proximidades da Escola Estadual Jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda, a qual dava conta que três indivíduos que se encontravam próximo a escola fazendo tráfico de substâncias entorpecentes.

Juntamente com seus colegas Leandro e Edson rumaram para o local denunciado e lá chegando lograram encontrar três indivíduos com as características denunciadas, sendo que um deles conseguiu empreender fuga do local, sendo identificados como sendo as pessoas de IAGO TAVARES MARTINS; EVERSON RODRIGO MARQUES DE SOUZA DOS SANTOS E VINÍCIUS AGOSTINHO, sendo certo que o indivíduo EVERSON figurava como "olheiro" de IAGO E VINÍCIUS, sendo todos abordados. Que, na posse de IAGO e VINÍCIUS foram encontradas as substâncias entorpecentes embaladas para venda e objetos acima descritos, cumprindo destacar que no momento da abordagem os increpados desobedeceram a ordem legal a eles dada, bem como, resistiram a prisão, sendo usado de força moderada para contê-los. Que, foi dada voz de prisão em flagrante delito a IAGO TAVARES MARTINS, EVERSON RODRIGO MARQUES DE SOUZA DOS SANTOS E VINÍCIUS AGOSTINHO, na forma do artigo 33 cabeça da Lei 11343/06, combinado com artigo 35 e 40 inciso III da Lei 11343/06, combinado com artigos 329 e 330 do Código Penal Brasileiro, sendo todos conduzindo para esta unidade policial, onde a autoridade policial ciente dos fatos ratificou a voz de prisão anteriormente dada e determinou fosse lavrado em desfavor dos increpados a competente peça coercitiva. O local onde estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes fica próximo a Escola Estadual Jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda, e o indivíduo EVERSON que tinha o papel de olheiro para os demais membros ficava na frente de um bar na mesma rua no numeral 792, sendo este incumbido de avisar aos demais quanto a chegada da Polícia bem como indicava também a usuários o local exato de onde estava sendo realizado o comércio de entorpecentes. "

A testemunha Edson Bury Roso, em fase policial (fls. 18), corroborou o relato de Rogerio Grolla.

A testemunha Leandro Luiz Martins, em fase policial (fls. 20), corroborou o relato de seus colegas.

Os policiais ouvidos durante audiência, confirmaram que receberam uma denúncia

acerca de tráfico de entorpecentes em local próximo a uma escola, razão pela qual dirigiram-se até lá para averiguação. Após breve campanha, onde detectaram movimentação típica de compra e venda de entorpecentes resolveram abordar os presentes e, tão logo se aproximaram deram voz de prisão. Eram quatro elementos, porém um deles veio a se evadir do local. As drogas estavam na frente de um portão, com dois dos envolvidos e, quando adentraram ao imóvel (uma vila bem simples com casas num corredor comum), avistaram outra quantidade de entorpecentes (numa outra sacola) localizada próximo a um muro que existe no local, no interior de um buraco. Dois dos envolvidos estavam vendendo os entorpecentes, enquanto o terceiro estava na função de "olheiro". De fato, o local da prisão dos réus era aproximadamente a trinta metros de uma escola.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. É fato que o policial Edson apontou como sendo "olheiro" o réu Iago, enquanto os demais policiais apontaram a pessoa do corréu Everson. Contudo, os próprios policiais esclareceram em Juízo que apuram grande quantidade de denúncias envolvendo tráfico de entorpecentes e, ante o lapso temporal decorrido, reputo normal pequenas confusões acerca de detalhes envolvendo a ocorrência policial. O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão dos réus Yago e Vinícius, pela quantidade e diversidade da droga apreendida, confirmadas pelo laudo de fls. 172/174, montante consistente em um total de 43 g de substância em que foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); um total de 2850 g de substância em que NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); total de 11 g de substância em que foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); um total de 108,1 g em que foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), corroborado pela narrativa dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Destaque-se, por oportuno, que a quantidade e a diversidade da droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, visto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória.

A quantidade, a variedade e o modo de disposição das drogas (embaladas individualizadas) e as circunstâncias em que apreendidas, em ponto conhecido como sendo de tráfico de drogas, mostram-se compatíveis com destinação para o comércio ilícito.

Isto em conjunto com as demais provas amealhadas em regular instrução em juízo, denotam a incidência da conduta tipificada no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. No que toca à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, pelo fato de o crime ter sido praticado nas cercanias de uma escola (a Escola Estadual Jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda), entendo ser o caso de seu reconhecimento.

A essência do dispositivo reside no aproveitamento de aglomerações nesses locais

para a difusão da droga. No caso dos autos, verifica-se que foi praticado em uma quinta-feira, por volta de 14 horas.

Embora os policiais não tivessem narrado em seus depoimentos se havia movimentação de alunos da escola, mencionaram que o local da abordagem distava trinta metros do estabelecimento de ensino, fato este confirmado pelos próprios acusados. Donde se infere que é circunstância apta a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, incidindo a majorante, portanto. Quanto à tese defensiva de que os réus Iago e Vinícius fariam jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, verifica-se que, de fato, são primários, não possuem maus antecedentes como se observa de fls. 49/50 (Vinícius) e fls. 51/52 (Iago).

A prática anterior de atos infracionais pelo acusado (fls. 49) não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (STF, AgRg no HC 191.992, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 08.04.2021).

Não há indícios, nos autos, de que se dediquem a atividades criminosas ou que integrem organização criminosa, em que pese a expressiva quantidade de drogas encontrada.

Contudo, considerando-se que traficavam elevada quantidade de drogas, com grande diversidade, especialmente, dentre outras, cocaína, que possui natureza altamente nociva, apta a gerar dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga, a fração de diminuição da pena será de 1/3 (um terço).

Destaco, por fim que, para não incorrer em bis in idem, as circunstâncias da quantidade e natureza da droga não serão utilizadas na primeira fase da dosimetria, já que foram consideradas para fixação de patamar menos elevado da causa de diminuição de pena (STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 (repercussão geral)).

Já o réu Everson é reincidente, havendo indícios de que se dedica a atividades criminosas, como se verifica da certidão de fls. 53/54 e FA (fls. 63 - pena extinta em 12.08.2021) razão pela qual não faz jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei 11.343/06).

Quanto ao crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, relativo à associação para o tráfico, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu balizas para aferição de sua incidência, sustentando-se que, para a caracterização de tal crime, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo.

Ocorre que não restou configurado nos autos o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Não se logrou comprovar, por exemplo, uma estrutura de divisão de tarefas, com atividades atribuídas de modo permanente a cada um dos elementos e tampouco o vínculo duradouro entre eles. Caracteriza-se, portanto, mero concurso de pessoas. Desta forma, pela não comprovação do caráter estável e permanente da associação, é o caso de absolvição quanto a este imputação, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão dos réus Yago e Vinícius, corroborada pela narrativa da pormenorizada dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.

E, frise-se também que a versão dos fatos apresentada pelo corréu Everson no sentido de que, somente foi conduzido ao Distrito Policial porque registrava passagens policiais anteriores, não se coaduna com a prova oral e documental produzida nos autos. Isso porque não é crível que policiais civis que não conheciam o acusado antes dos fatos tivessem intenção deliberada de prejudicá-lo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência parcial da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusados, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

RÉU IAGO TAVARES MARTINS

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas

pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei nº11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifica-se que nenhuma das circunstâncias elencadas têm o condão de agravar a pena base do réu, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, fica mantida a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, tem-se a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2.006, no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mas, incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º, do artigo 33, incide no patamar de 1/3 (um terço) como já salientado na fundamentação. Vão as penas, pois, a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime ABERTO, conforme artigo 33, §2º, c do Código Penal.

Não se aplica o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, já que fixado regime mais favorável.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução número 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável, especialmente considerando-se a natureza e diversidade das drogas apreendidas (artigo 44, inciso III, e § 3º, CP), bem como o local da prática do crime.

Tampouco faz jus ao sursis (artigo 77, caput, Código Penal), pela quantidade de pena aplicada.

RÉU VÍNICIUS AGOSTINHO

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifica-se que nenhuma das circunstâncias elencadas têm o condão de agravar a pena base do réu, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, fica mantida a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, tem-se causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2.006, no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mas, incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º, do artigo 33, incide no patamar de 1/3 (um terço) como já salientado na fundamentação. Vão as penas, pois, a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime ABERTO, conforme artigo 33, §2º, "c" do Código Penal.

Não se aplica o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, já que fixado regime mais favorável.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução número 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável, especialmente considerando-se a natureza e diversidade das drogas apreendidas (art. 44, inciso III, e § 3º, CP), bem como o local da prática do crime.

Tampouco faz jus ao sursis (artigo 77, caput, Código Penal), pela quantidade de pena aplicada.

RÉU EVERSON RODRIGO MARQUES DE SOUZA DOS SANTOS

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu possui maus antecedentes (fls. 53/54 – processo 0027154-91.2010.8.26.0050), devendo incidir aumento de 1/6 (um sexto). Destaco que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura bis in idem a utilização dos maus antecedentes para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC 635.594, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.03.2021).

Culpabilidade, conduta social e personalidade não destoam do ordinário, não devendo ser valoradas.

Quanto às circunstâncias, motivos e consequências do crime também não há nada nos autos que evidenciem a necessidade de maior reprimenda.

Fica a pena base, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é reincidente (processo 0033350-09.2012.8.26.0050 – extinta punibilidade em 12.08.2021), devendo incidir aumento de 1/6 (um sexto). Incide aumento de mais 1/6 (um sexto).

Fica a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, tem-se a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2.006, no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Mas, por se tratar de reincidente, não incide o redutor legal previsto pelo parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2.006.

Vão-se as penas, pois, a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus

1) IAGO TAVARES MARTINS, por infração ao artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Com fundamento no artigo 386, inciso VII, ABSOLVO o acusado IAGO da imputação de prática do delito tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2.006;

2) VINÍCIUS AGOSTINHO, por infração ao artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado VINÍCIUS da imputação de prática do delito tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2.006 e;

3) EVERSON RODRIGO MARQUES DE SOUZA DOS SANTOS, por infração ao artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Com fundamento no artigo 38, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado EVERSON da imputação de prática do delito tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2.006.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado EVERSON no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

As razões que aqui vinham motivando a manutenção da prisão cautelar de IAGO e VINÍCIUS comportam reexame frente ao regime ora imposto, razão pela qual revogo a prisão preventiva e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outra razão estiver preso.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 31 de agosto de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA